

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
13689/2553

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด  
สวรรคโลก

นางเสมอใจ นิตีธรรม

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 2, มาตรา 3

ป.วิ.อ. มาตรา 212, มาตรา 225

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 40, มาตรา 42, มาตรา 66 ทวิ

เมื่ออาคารที่จำเลยครอบครองต่อจาก ส. ซึ่งถึงแก่ความตาย ปลูกสร้างห่างจาก  
เขตที่ดินข้างเคียง 45 เซนติเมตร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวงและเทศบัญญัติของ  
เทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2500 และเป็นกรณี  
ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงขอที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งให้  
จำเลยรื้อถอนอาคารได้ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42 แม้ก่อน  
โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน  
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กำหนดข้อยกเว้นให้สามารถก่อสร้างผนังของอาคาร  
ห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตรได้ หากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก  
เจ้าของที่ดินข้างเคียงในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดิน และ ข. เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้  
ทำหนังสือยินยอมเช่นว่าให้แก่ ส. ซึ่งเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว อันแตกต่างไปจาก  
กฎหมายเดิมที่ใช้ขณะจำเลยกระทำความผิดและเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่าตาม ป.อ.  
มาตรา 3 วรรคแรก ก็ตาม แต่ก็มีใช้เป็นกฎหมายยกเว้นความผิดของจำเลยที่ฝ่าฝืน  
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นความผิดสำเร็จไปแล้วกลับกลาย

เป็นไม่เป็นความผิด จำเลยจึงยังไม่พ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตาม ป.อ. มาตรา 2 แต่เมื่อจำเลยไม่ต้องรื้อถอนอาคารพิพาทโดยผลของกฎหมายดังกล่าว ก็ไม่อาจลงโทษปรับจำเลยรายวันไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ คงลงโทษปรับจำเลยรายวันได้เพียงถึงวันก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษปรับรายวันนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป อันเป็นเวลาภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) มีผลใช้บังคับแล้วนั้นแม้เป็นการไม่ถูกต้อง แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาในข้อดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขกำหนดโทษให้ถูกต้องได้เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยต้องห้ามตาม ป.วิ.อ. มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, 40, 42, 66 ทวิ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, 40, 42, 66 ทวิ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จำคุก 4 เดือน และปรับ 40,000 บาท กับให้ปรับรายวันอีกวันละ 1,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 กรกฎาคม 2544) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนอาคารเสร็จ โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อปี 2530 นายสมพร สามิ ของจำเลย ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลเมืองสวรรคโลก ให้ก่อสร้างอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 คูหา บนที่ดินโฉนดเลขที่ 4580 ถึง 4582 ซึ่งเป็นที่ดินของนายสมพรกับจำเลย รวมพื้นที่ 728 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ อยู่อาศัย เมื่อปี 2541 นางสาวชนพิศ เจ้าของที่ดินข้างเคียงร้องเรียนต่อเทศบาล เมืองสวรรคโลกว่า นายสมพรก่อสร้างอาคารรุกล้ำที่ดินของนางสาวชนพิศ ในปี 2542 นายสมพรถึงแก่ความตาย จำเลยจึงครอบครองอาคารดังกล่าวแทน ต่อมาในปี 2543 นางสาวชนพิศร้องเรียนต่อเทศบาลเมืองสวรรคโลกอีก เทศบาลเมือง สวรรคโลกจึงไปตรวจสอบอาคารดังกล่าวอีกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2543 พบว่าการ ก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องโดยตัวอาคารจากผนังด้านนอกมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ข้างเคียง 45 เซนติเมตร ซึ่งต่ำกว่า 50 เซนติเมตร และมีส่วนที่ยื่น ได้แก่ กันสาด และท่อน้ำทิ้ง 2 แท่ง ผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบ แปลนที่ได้รับใบอนุญาต ตลอดจนวิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ ในใบอนุญาต และฝ่าฝืนเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ควบคุมการ ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2500 ข้อ 60 นายสมชาติ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง สวรรคโลกในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้จำเลยในฐานะเจ้าของและผู้ครอบ ครอบรือถอนอาคารบางส่วนรวม 3 ครั้ง ตามคำสั่งลงวันที่ 13 มีนาคม 2543 วันที่ 25 เมษายน 2543 และวันที่ 5 มิถุนายน 2543 จำเลยทราบคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2543 วันที่ 3 พฤษภาคม 2543 และวันที่ 7 มิถุนายน 2543 ตามลำดับ

แต่จำเลยเพิกเฉย ไม่ยอมรื้อถอนภายในกำหนดและไม่ได้อุทธรณ์คำสั่ง ตามสำเนาคำสั่งและใบตอบรับในประเทศ คงมีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอนอาคารพิพาทหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่า นางสาวชวนพิศไม่ได้ยินยอมให้นายสมพรปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินโดยวิธีทำผนังร่วมกัน จึงไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะดำเนินการได้ เห็นว่า ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2498) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ข้อ 56 วรรคสอง และเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2500 ข้อ 60 วรรคสอง บัญญัติว่า อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้นจะมีระยะห่างจากเขตที่ดินต่ำกว่า 50 เซนติเมตรไม่ได้ เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธีตกลงทำผนังร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม เมื่ออาคารพิพาทอยู่ห่างจากเขตที่ดินของนางสาวชวนพิศ 45 เซนติเมตร อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวและเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงชอบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งได้แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลกจะมีคำสั่งให้จำเลยรื้อถอนอาคารได้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42 ส่วนจำเลยนำสืบอ้างว่านางสาวชวนพิศได้ทำหนังสือให้ความยินยอมไว้ ประกอบกับปรากฏว่าก่อนโจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้มีกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 แล้ว ซึ่งในข้อ 50 บัญญัติว่า ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตูช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินดังนี้

(1) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แต่ไม่ถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าที่กำหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 15 เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาตฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาตฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

ดังนี้ แม่นางสาวชวนพิศได้ทำหนังสือให้ความยินยอมไว้ โดยยินยอมให้นายสมพรปลูกสร้างอาคารพิพาทชิดแนวเขตที่ดินได้ กับทั้งไม่ปรากฏว่าผนังของอาคารพิพาทไม่ใช่ผนังทึบและไม่ปรากฏว่าอาคารพิพาทมีดาตฟ้าที่ต้องทำผนังทึบสูงจากดาตฟ้าไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ซึ่งเข้าข่ายยกเว้นที่ทำให้สามารถที่จะปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินในระยะต่ำกว่า 50 เซนติเมตรได้ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) อันแตกต่างไปจากกฎหมายเดิมที่ใช้ในขณะจำเลยกระทำความผิดและเป็นคุณแก่จำเลยมากกว่า จำเลยย่อมได้รับประโยชน์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 วรรคแรก ก็ตาม แต่ก็มีใช่เป็นกฎหมายที่ยกเว้นความผิดของจำเลยที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวซึ่งมีผลเป็นความผิดไปแล้วนั้นกลับกลายเป็นไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด จำเลยจึงยังไม่พ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 แต่อย่างไรก็ตาม โดยผลของกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) อาคารดังกล่าวสามารถปลูกสร้างห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงในระยะที่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร ได้ อันเนื่องจากความยินยอมของนางสาวชวนพิศเจ้าของที่ดินข้างเคียงจำเลยจึงไม่ต้องรื้อ

ถอนอาคารส่วนที่อยู่ห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงในระยะที่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร อีก  
แต่ยังถือว่าจำเลยมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีผลสำเร็จไปแล้ว  
จนถึงก่อนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) มีผลใช้บังคับ กล่าวคือ นับถัด  
จากวันพ้นกำหนด 30 วัน หลังจากจำเลยทราบคำสั่งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มีนาคม  
2543 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2543 อันเป็นวันก่อนวันที่กฎกระทรวงดัง  
กล่าวมีผลบังคับใช้เท่านั้น จึงสามารถลงโทษปรับจำเลยรายวันได้เพียงช่วงระยะเวลา  
ดังกล่าว แต่ไม่อาจลงโทษปรับรายวันไปจนกว่าจำเลยจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้า  
พนักงานท้องถิ่นโดยการรื้อถอนอาคารพิพาทได้ ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6  
พิพากษายกฟ้องมานั้น จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น  
บางส่วน

ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษปรับรายวันนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป อันเป็น  
เวลาภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) มีผลใช้บังคับแล้วนั้น ก็  
เป็นการไม่ถูกต้องเช่นกัน แต่เมื่อโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาในข้อที่ศาลชั้นต้นมิได้ปรับ  
จำเลยรายวันในช่วงระยะเวลาก่อนวันฟ้อง ศาลฎีกาจึงไม่อาจแก้ไขกำหนดโทษให้ถูก  
ต้องได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลย ซึ่งต้องห้ามตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 212 ประกอบมาตรา 225

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เว้นแต่โทษปรับราย  
วันให้ยก

(ประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล-นิยุต สุภัทรพาหิรผล-วิรุฬห์ แสงเทียน)

ศาลจังหวัดสวรรคโลก - นายอนุรุต กิ่งเนตร

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 - นายรังสรรค์ ดวงพิตร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ1043/2545

ต้น

หมายเหตุ